

刑法
No48

H27-9

(配点: 3)

月	日
月	日

次の【事例】に関する1から5までの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

【事例】

Aは、外国へ旅行に行った際、旅行先で知り合ったBから、荷物を預けるので手荷物として日本まで運んでほしいと依頼され、これを了承し、その荷物を日本に持ち込んだが、荷物の中身は覚せい剤であった。

なお、覚せい剤をみだりに日本に持ち込んだ場合には覚せい剤取締法の輸入罪が成立し、麻薬をみだりに日本に持ち込んだ場合には麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立するものとする。

【記述】

1. Aは、Bから預かった荷物の中身は「薬物ではない。」と聞かされていたが、「薬物以外の何か違法なものかもしれない。」と思ってこれを日本に持ち込んだ場合、Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
2. Aは、Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤である。」と思ったものの、覚せい剤を日本に持ち込むことは法律上禁止されていないと考えてこれを日本に持ち込んだ場合、Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
3. Aは、Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤である。」と聞かされたものの、覚せい剤が違法な薬物であることを知らず、「覚せい剤とは高価な化粧品のことである。」と認識してこれを日本に持ち込んだ場合でも、「覚せい剤」という認識がある以上、Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
4. Aは、Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤かもしれないし、もしかしたら麻薬かもしれない。」と思ってこれを日本に持ち込んだ場合、Aには客体の認識に錯誤があり、麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪の法定刑が覚せい剤取締法の輸入罪の法定刑よりも軽いときには、Aには麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立する。
5. Aは、Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤ではないが、麻薬である。」と思ってこれを日本に持ち込んだ場合、覚せい剤取締法の輸入罪の法定刑と麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪の法定刑が同じときには、Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。

No.48	抽象的事実の錯誤	正答率
H27-9	正解 2、5（順不同）	49%

1 誤っている

最決平2.2.9（百選140事件）。判例は、本記述の事例と同様の事案において、「被告人は、本件物件を密輸入して所持した際、覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があったというのであるから、覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識はあったことに帰することになる。そうすると、覚せい剤輸入罪、同所持罪の故意に欠けるところはない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないという、いわゆる「類」の認識があり、覚せい剤を除外していなければ、その概括的な認識の中に「覚せい剤」の未必的な認識も含まれるということを挙げている。本記述では、Aは、Bから預かった荷物の中身が「薬物以外の何か違法なものかもしれない。」と思っていたにすぎず、Aには、覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識がなかったといえる。よって、Aには、覚せい剤取締法の輸入罪の故意が認められず、同罪は成立しない。

2 正しい

38条3項。法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減輕することができる。これは、法律の錯誤に関する規定であり、法律の知不知が犯罪の成否を左右するものではないことを定め、責任主義は事実の認識面に関するものであることを明らかにしたものである。本記述では、Aは、Bから預かった荷物の中身が「覚せい剤である。」と思ったため、覚せい剤取締法の輸入罪の犯罪事実を認識しているので、同時に覚せい剤を日本に持ち込むことは法律上禁止されていないと考えていたとしても、38条3項本文適用によって故意は否定されない。よって、Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。

3 誤っている

本記述では、Aは本来違法な薬物である覚せい剤について、「覚せい剤とは高価な化粧品のことである。」と認識していたため、このようなAの錯誤が事実の錯誤に当たるか、法律の錯誤（違法性の錯誤）に当たるかが問題となる。事実の錯誤とは、行為者が認識していた犯罪事実と異なる犯罪事実が発生することをいう。これに対して、法律の錯誤は、行為者が錯誤によって違法性の意識を欠いた場合をいう。犯罪事実の認識は、それによって行為者に違法性の意識を喚起し、違法行為を思いとどまり適法行為に出よう動機付けけるものであるから、この認識を誤ると違法性の意識が喚起される契機がなくなってしまう。そのため、事実の錯誤の場合には故意が否定される。他方、法律の錯誤は、違法性の意識を喚起し得る事実を認識しながら、何らかの理由で違法性の意識を喚起しないまま犯罪を実行した場合であるため、原則として故意を阻却しない。そうすると、両者の区別は、違法性の意識を喚起し得る程度の実事の認識を有していたか否かによって決するとされている。本記述では、Aは、Bから預かった荷物の中身が「覚せい剤」という認識はあるものの、「覚せい剤とは高価な化粧品のことである。」と明確に認識しており、これが違法な薬物であるという認識を欠いていた。つまり、Aは違法性の意識を喚起し得る程度の実事の認識を有していなかったといえる。よって、Aの錯誤は事実の錯誤に当たるから、覚せい剤取締法の輸入罪の故意が阻却され、同罪は成立しない。

4 誤っている

最決平2.2.9（百選I40事件）。判例は、本記述の事例と同様の事案において、「被告人は、本件物件を密輸入して所持した際、覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があったというのであるから、覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識はあったことに帰することになる。そうすると、覚せい剤輸入罪、同所持罪の故意に欠けるところはない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないという、いわゆる「類」の認識があり、覚せい剤を除外していなければ、その概括的な認識の中に「覚せい剤」の未必的な認識も含まれるということを挙げている。本記述では、Aは、Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤かもしれないし、もしかしたら麻薬かもしれない。」と思っていたため、覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があったといえる。そのため、Aには覚せい剤取締法の輸入罪に当たる犯罪事実の認識があったことになるから、客体の認識に錯誤はない。よって、Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。

5 正しい

最決昭54.3.27。判例は、主観的には覚せい剤取締法の輸入罪を犯す意思で、客観的には麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪に当たる事実を実現した事案において、「両法は、その取締の目的において同一であり、かつ、取締の方式が極めて近似して、輸入、輸出、製造、譲渡、譲受、所持等同じ態様の行為を犯罪としているうえ、それらが取締の対象とする麻薬と覚せい剤とは、ともに、その濫用によつてこれに対する精神的ないし身体的依存（いわゆる慢性中毒）の状態を形成し、個人及び社会に対し重大な害悪をもたらすおそれのある薬物であつて、外観上も類似したものが多くことなどにかんがみると、麻薬と覚せい剤との間には、実質的には同一の法律による規制に服しているとみうような類似性があるというべきである。」とし、「両罪は、その目的物が覚せい剤か麻薬かの差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素は同一であり、その法定刑も全く同一であるところ、前記のような麻薬と覚せい剤との類似性にかんがみると、この場合、両罪の構成要件は実質的に全く重なり合っているものとみるのが相当であるから、麻薬を覚せい剤と誤認した錯誤は、生じた結果である麻薬輸入の罪についての故意を阻却するものではない」としている。このように、判例は、認識していた犯罪事実と発生した犯罪事実とが法定刑において同じ重さである場合には、発生した犯罪事実についての故意が認められ、その罪が成立するとしている。本記述では、Aは、主観的には麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪を犯す意思で、客観的には覚せい剤取締法の輸入罪に当たる事実を実現したものであるが、覚せい剤取締法の輸入罪の法定刑と麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪の法定刑は同じであり、客観的に発生した覚せい剤取締法の輸入罪についての故意が認められる。よって、Aには、覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。